

1506265-26.2020.8.26.0136

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... sentido, decisão da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena.

IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506265-26.2020.8.26.0136 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506265-26.2020.8.26.0136

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2058093/2020 - DEL.POL.IARAS, 6527934

- DEL.POL.IARAS, 79/18/117 - DEL.POL.IARAS, 2058093 - DEL.POL.IARAS, 79/18/117 -

DEL.POL.IARAS, 2058093 - DEL.POL.IARAS, 79/18/117 - DEL.POL.IARAS

Autor:

Justiça Pública

Cidadão, Réu:

MARIA CONCEIÇÃO MARIANO DE OLIVEIRA, JOAO PAULO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 26 de abril de 2018, pela manhã, no interior da Penitenciária de Iaras, situada na Rodovia Dr. Jair Gilberto Campanati, Km 04, cidade de Iaras/SP, nesta comarca de Cerqueira César/SP, transportou, para fins de tráfico, 31 porções de maconha, com peso líquido de 64,840 gramas, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. Laudo preliminar, fls. 16/18 e auto de exibição e apreensão, fls. 09/11).

Portaria e demais peças do inquérito policial a fls. 01/70. A denúncia foi oferecida em 23 de novembro de 2021(fl.168/170), e o réu notificado a fls.211,

ofereceu Defesa Prévia a fls.226/227 . Foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 228/229). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 232).Em audiência, foram inquiridas 02 testemunhas em comum e o réu interrogado (fls. 258/259 e 306/307 e gravações audiovisuais).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls.306/307). A douta Defesa , por sua vez, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso III , do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, a aplicação do parágrafo 4º, do art. 33 da lei de drogas e a fixação da pena no mínimo legal (fls.314).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, " nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado transportou 31 porções de maconha para dentro do presídio, através de uma correspondência enviada a ele, por sua determinação, pelos correios.Ocorre que, a encomenda foi revistada pelos agentes penitenciários, sendo as porções localizadas entre os pacotes de torradas, na encomenda enviada via SEDEX, com o nome da genitora do denunciado, tendo por destinatário JOÃO PAULO. " No mérito, à luz da prova produzida, a denúncia procede integralmente.

A materialidade delitativa restou configurada pelo boletim de ocorrência a fls. 03/04, auto de exibição e apreensão a fls. 09/11, fotografias (fls.12/14), laudo toxicológico a fls. 16/18, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitativa, de igual modo, também restou incontestada e recai sobre o réu.

A testemunha de acusação Marcelo Carlos de Godoy , agente penitenciário, disse "que no dia dos fatos, estava trabalhando no setor de inclusão, local onde se recebem os Sedex. Ao realizar o procedimento, encontraram no pacote enviado pela mãe do acusado, as drogas, supostamente, maconha. Questionado o réu confirmou que havia pedido a droga"

Loukevin Augusto Rodrigues de Castro, agente penitenciário, judicialmente, " relatou que no dia dos fatos, foi apreendida a droga endereçada ao réu na revista. Nesses dias, teve várias tentativas de passar droga. Disse que no dia todos os réus que tiveram a correspondência apreendida afirmaram que tinham solicitado a droga. "

O réu João Paulo de Oliveira, em seu interrogatório judicial, disse " que não falou com sua mãe e que ela não tinha ciência dessa droga. Na hora que chegou na inclusão, a caixa já estava aberta e a droga estava em cima de uma caixa. Relatou que na sindicância disse que a droga era dele, para seu uso pessoal, e que sua mãe não sabia de nada. Pediu para que um amigo enviasse a droga, porque estava em abstinência. Confirmou que a droga era dele e foi remetida a pedido dele".

Com efeito, verifico que a versão dada pelo réu no sentido de que as drogas eram destinadas somente para seu consumo pessoal não merece acolhida, revelando, apenas, uma tentativa infrutífera de eximir-se da imputação que lhe é feita com o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos agentes penitenciários e a prova da materialidade.

Ademais, da fase inquisitiva à judicial, os depoimentos prestados pelos agentes foram firmes e seguros, não se vislumbrando qualquer interesse em acusar ou prejudicar o réu, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada. Não se pode conceber a justificativa rasa de que os agentes públicos permanecem perseguindo cidadãos e atribuindo-lhes a propriedade de quantia tão grande de entorpecente com o único fim de prejudicar o réu.

Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só

fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na

investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) "(g.n.).

Neste interim, a alegação do réu de que é usuário de drogas, por si só, não retira a convicção de que também traficaria. Prova do alegado vício era ônus que lhe pertencia do qual, porém, não se desincumbiu. Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado. Neste sentido, decisão da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena.

IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. TJ-SP -

Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125.

Julgamento:12/08/2014 (grifo nosso)

Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ademais, inobstante o réu afirme que as drogas eram para uso próprio, em seu poder não foram encontrados apetrechos ou instrumentos utilizados para o consumo de drogas, ressaltando a finalidade mercantil dos entorpecentes. Por fim, as drogas foram encontradas em pequenas porções, forma de acondicionamento própria da venda "a varejo" de entorpecentes, restando devidamente demonstrada a finalidade comercial das drogas.

O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Dessa maneira, basta a conduta de guardar, ter em depósito ou trazer consigo a droga, desde que evidenciada a finalidade de entrega a terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, essa finalidade está bem evidenciada, eis que a quantidade de droga apreendida (31 porções de maconha, peso líquido de 64,840 g) é fator considerável à caracterização do tráfico, tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas.

Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.)."

In casu, o réu admitiu que havia solicitado a droga a ser-lhe enviada pelo correio. De outra feita, também, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução.

Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que a ré praticava o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 . Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta

antecedentes maus antecedentes(F.A. e certidões a fls. 180/197) e, além disso encontra-se em cumprimento de pena. Isso mostra que tem conduta social reprovável e personalidade voltada à delinquência, já que a mais grave das penas ordinariamente previstas em nossa legislação penal não o intimidou a praticar novo delito. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), atingindo a quantia de 05(cinco) anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 192/193), por essa razão, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 6 (seis)anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa. Na terceira fase, elevo a pena em 1/6 (um sexto), eis que presente a causa de aumento do inciso III do art. 40 da lei 11.343/06, pois o réu tentou adentrar com a droga em estabelecimento prisional. Não incide a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não preenche todos os predicados legalmente previstos, precipuamente, a reincidência. Nesse sentido: “Não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade e a natureza da substância apreendida levaram à conclusão de que o paciente se dedica a atividades delituosas, ou seja, não se trata de traficante ocasional” (HC 297447/RS, Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/11/2014). E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pela reincidência e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-se: “A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes” (HC 214069/SP – Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 7(SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA , COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

A pena imposta ao réu deverá ter seu início de cumprimento em regime FECHADO. Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não concluiu, por outro lado, pela imposição indiscriminada de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena em tais delitos. Ao contrário. Ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, o STF permitiu a adoção de regime inicial mais severo quando presentes elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59 do Código Penal (cf. HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/12/2013). O caso dos autos, no qual se constatou a prática de tráfico de considerável quantidade de entorpecente, demanda a adoção de regime prisional mais severo, sob pena de se produzir, como efeito colateral de um arrefecimento despropositado da reprimenda estatal, uma sensação de impunidade àqueles que demonstram desprezo à manutenção da ordem pública. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og

Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP.

Ausentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar do réu. Sendo assim, nos termos do artigo 387, parágrafo único, c.c. artigo 312, ambos do CPP, o réu poderá apelar em liberdade.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome dos réus/condenados recorrentes, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) dos condenados; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, com as devidas identificações, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Cerqueira Cesar, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA